



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 147/11 + 132/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

התובע
הנתבע שכנגד: רפי כהן
ע"י ב"כ עוה"ד משה חן
מרחוב שמעוני 35 ירושלים

הנתבע
התובע שכנגד: נ ג ד
הרצל בנימין
ע"י ב"כ עוה"ד אמיר שלום
מרחוב אגריפס 8 ירושלים

פסק דין

הצדדים הינם בעלי דירות בבית ברחוב הורקניה 3 ירושלים הבנוי על חלקה 82 בגוש 30171 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי.

בבית 4 דירות ב- 2 קומות. דירת התובע ממוקמת מעל דירת הנתבע.

התובע טוען כי הנתבע סגר את הגישה לבניין הראשי המשותף של הבית והוא מסרב להחזיר המצב לקדמותו. לטענת התובע, לפיר הבניין היתה גישה דרך מחסן בקומת הקרקע שהיה בחזקתו. לאחר שקיבל הנתבע את החזקה במחסן, בהתאם להסכם בין הצדדים, הוא חסם את הגישה לבניין והרחיב את חדר האמבטיה כך שהפיר נעשה צפוף.

הנתבע טוען כי המחסן מצוי במצבו כפי שהיה החל משנת 1985. התובע הוא זה שהחזיק במחסן מאז 1998 (על פי החלטת בית משפט) ומאז 2006 נמסר המחסן לנתבע, במצבו כפי שהוא כיום. בהקשר זה טוען הנתבע כי התובע ביקש להפוך את המחסן ליחידת מגורים ואף החל בביצוע עבודות בהתאם לרבות פריצת חלון וחפירה ביסודות. העבודות נעצרו בהחלטה שיפוטית ביוזמתו של הנתבע. לטענת הנתבע המעבר לבור הבניין הינו דרך ביתו של השכן אשר סגר את המעבר שהיה קיים ופתח במקומו דלת מעבר דרך דירתו.

ביחד עם כתב ההגנה הגיש הנתבע תביעה שכנגד במסגרתה תבע תשלום פיצוי בגין ההטרדה בתובענה שהוגשה. כן טען כי על הנתבע שכנגד להסיר את קיר האבן שבנה על גג הבית, המונע הגעת שמש לקולטים. לטענת התובע שכנגד ההסכמה שבין הצדדים היתה לבניית גדר אבן מסביב הגג ולא באמצעו.

הנתבע שכנגד הגיש כתב הגנה שכנגד וטען כי התובענה שכנגד קנטרנית ולא באה אלא כתגובה לתביעה שהוגשה. מכל מקום, על פי ההסכם שבין הצדדים היה על התובע שכנגד להעתיק את דוד השמש שלו מגג הבית למיקום אחר. הנתבע שכנגד מכחיש כי התכוון להשמיש את המחסן למגורים. אומנם, נפתח חלון. אולם, מטרתו היתה ליצור חוצץ בין המחסן לבין מעבר לבור הבניין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 147/11 + 132/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

הנתבע שכנגד שב וטוען כי היתה במחסן דלת עץ למעבר לבור הביוב והתובע שכנגד הוא זה אשר סגר אותה.

ביום 27.09.11 התקיים דיון מקדמי בתובענה, בסיומו נקבעה פרוצדורה להגשת ראיות הצדדים.

התובע/נתבע שכנגד הגיש תצהיר עדות ראשית מטעמו.

הנתבע/תובע שכנגד הגיש תצהיר עדות ראשית מטעמו וכן חוות דעת הנדסית. המהנדס אילן אליהו לא התייצב לחקירה על חוות דעתו ומשכך ויתר הנתבע/תובע שכנגד על העדתו.

העדים נחקרו על תצהיריהם ביום 10.01.12 ולאחר מכן סיכמו הצדדים בכתב את טענותיהם.

לנתבע שכנגד ניתנה הזכות לסיכומי תגובה בתביעה שכנגד. אולם, הוא לא הגיש סיכומים כנ"ל ומשחלף המועד להגשתם ניגשתי למתן פסק דין זה.

דיון

התביעה העיקרית

הנטל להוכחת התביעה מוטל על שכמו של התובע בבחינת הכלל הידוע בהליך האזרחי לפיו "המוציא מחברו עליו הראיה". נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות, קרי, הגרסה ה"מסתברת יותר" (י. קדמי על הראיות הפן האזרחי – קובץ הרצאות (תש"ן) בעמ' 333).

במקרה דנן, לאחר שקילת מכלול הראיות שבפני, הרי שהתובע לא עמד במאזן הנדרש זה להוכחת תביעתו.

אין מחלוקת בין הצדדים כי הנתבע מחזיק במחסן נשוא התובענה בהתאם להסכם מיום 27.08.06 (נספח לתצהירי שני הצדדים) (להלן: "ההסכם"). התובע אינו מתכחש להסכם והוא אף מסתמך עליו במסגרת ראיותיו.

בהסכם נקבע כי המחסן מועבר "לרשות צד א' (הנתבע דנן, א.ס.) ולשימוש". אין בהסכם כל התייחסות לגישה למערכת הביוב. גם התובע מודע לכך - "ההסכם בשנת 2006 היה שאני מוותר על הזכויות למטה ובמחסן למעט גישה לגז וגישה לשעון מים, ואם יש לי צורך להשתמש למטה. לא כתבנו במפורש מנול אבל זאת הייתה הכוונה. ואני קיבלתי את הכל למעלה, הוא הוריד את הדוד" (עמוד 4 שורות 6-8).

דא עקא, לא עלה בידי התובע להוכיח כי במסגרת ההסכם שימר לעצמו את זכות הגישה למנהול דרך המחסן דווקא.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 132/11 + 147/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

ראשית, אין כל החרגה או סייג בנוגע לאפשרות השימוש במחסן על ידי הנתבע או לזכויות התובע למעבר כלשהו בו.

שנית, קבלת גרסת התובע בהקשר זה משמעה כי, למעשה, הנתבע קיבל לשימושו מחסן עם מגבלה משמעותית ביותר על אפשרות השימוש ואשר מחייבת מתן אפשרות מעבר בלתי מסויגת או צימצום שטח המחסן לשם יצירת מעבר. אולם, בכך אין כל הגיון כאשר הצד השני של אותו ההסכם נתן זכות שימוש בגג לתובע, כולל סילוק מתקנים של הנתבע מגג זה.

שלישית, כפי שטוען גם התובע, מטרת ההסכם היתה הפרדה מוחלטת בין הצדדים (עמוד 4 שורה 2). כך הם הסכימו בנוגע לגג והסרת מתקני הנתבע ממנו. קשה לראות כיצד היו אמורים להשיג מטרה זו באמצעות הותרת זכות גישה ומעבר דרך המחסן.

יוצא כי לשונו של ההסכם, וגם הגיונו, מלמדים על מתן זכות שימוש מוחלטת לנתבע במחסן. הא ותו לא.

לא עלה בידי התובע להוכיח בפני כי הנתבע ביצע עבודות כלשהן במחסן הבית או כי עובר לקבלת המחסן על ידי הנתבע על פי ההסכם היתה גישה לכיוב דרך המחסן.

הנתבע הציג בפני תמונות אשר צולמו לטענתו בשנת 1998 (מוצג נ/1). הנתבע גם העיד בהקשר זה "את התמונות בנ/1 לא צילמתי ב-2006 אלא ב-1998. הצגתי אותם בפני השופט מזרחי. יש לי עוד תמונות עם התאריך הזה" (עמוד 6 שורות 10-11). על גבי התמונות גם מצוין תאריך - 02.06.98.

מתמונות אלו ניכר כי אין מעבר או דלת לפיר המשותף – הבניה של הקיר הפנימי רצופה ואחידה ולא ניכרים סימנים כלשהם של סגירת פתחים. התובע מאשר כי התמונות משקפות את המצב הקיים כיום (עמוד 3 שורה 37). לא עלה בידי התובע לשכנע אותי במסגרת ראיותיו כי התמונות האמורות אינן משקפות מצב המחסן במועד שבו קיבל הנתבע את החזקה בו לידיו על פי ההסכם. בהקשר זה, אין מחלוקת כי התובע הוא זה אשר ביצע את עבודות החפירה במחסן וכן את פריצת הפתחים (סעיפים 2 ו-3 לכתב ההגנה שכנגד). ניכר כי התמונות הנ"ל צולמו במהלך ביצוע עבודות חפירה במחסן – במקום נראים אתי חפירה, סלים, דליים ושקית עם ציוד. הדבר תומך את טענת הנתבע לפיה התמונות צולמו בזמן ביצוע עבודות החפירה על ידי הנתבע ולא בעת האחרונה.

זאת ועוד. גם התובע צירף לתצהירו תמונות של המחסן (נספחים לתצהיר העדות). מסיבות השמורות עימו בחר התובע לצרף צילומים של תמונות בשחור לבן חלף הגשת התמונות המקוריות וללא כל תיעוד לגבי מועד הצילום. אף על פי כן, בתמונות אלו לא ניתן לראות את הפתח בקיר הבלוקים לקיומו טוען התובע. במקום בו נרשם "מחיצה מעץ עם דלת" ניכר כי המדובר בקיר מפריד ולא נראה שום פתח או דלת. ניכר גם כי החלון על הקיר האנכי אטום (כמצבו כפי שהוא כיום). בתמונה נוספת שצורפה (בתמונה בה נראה אדם עומד בתוך המחסן) נראה בבירור קיר הבלוקים הקיים כיום, ואין כל פתח בקיר זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 147/11 + 132/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

למעשה, אין בידי התובע כל ראיה לכך שבוצעו עבודות כלשהן במחסן על ידי הנתבע – אין בידו כל תמונה המוכיחה את טענותיו בדבר קיומו של מעבר בעבר, אין בידו אפילו טענה בדבר המועד שבו ביצע הנתבע את העבודות לחסימת הגישה לפתח הביוב לשיטתו.

למעלה מכך, הרי שלא עלה בידי התובע להוכיח כי בשנת 2005, כשיטתו, היה קיים מעבר לפתח הביוב. בהקשר זה יכול היה התובע להביא לעדות בפני את בעל המקצוע אשר ביצע את השיפוץ בביתו, ובפרט את בעל המקצוע אשר החליף את צנרת הביוב עד למנהול הראשי כטענתו. למעשה, לא עלה בידי התובע להוכיח כי בכלל בוצעו עבודות השיפוץ הנטענות, למשל, באמצעות הגשת חשבונית מס בגין ביצוע העבודה.

בהקשר כזה קובעת ההלכה כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"ל 1) 760, 736 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606).

בהעדר כל ראיה לביצוע העבודות בשנת 2005 (בין באמצעות חשבונית ובין באמצעות העדת אנשי מקצוע כאמור לעיל) ובהעדר כל הסבר מדוע לא הוגשו ראיות כנ"ל, ניתן להסיק מסקנות ראיות כנגד התובע כאמור לעיל.

בהקשר זה מקובלת עלי עדותו של הנתבע – "תמיד הגעתי למנול מסביב. עד לפני עשר שנים לערך היה שם חלל לכולם כל מי שרצה יכל לעבור לא הייתה היחידה של אפללו, לפני עשר שנים הם בנו את היחידה והכשירו אותה למגורים לבת שלהם והם אפשרו מעבר למנול כי הם ידעו שיש בעיה. הם השאירו פתח מתוך הדירה שהוא מצויין בתמונות" (עמוד 5 שורות 37-35).

לכך יש להוסיף את הודאת התובע כי, למעשה, עלה בידו להגיע לפתח הביוב אף ללא מעבר דרך המחסן – "אכן ירדתי מלמעלה בסולם מהגג עד המנול, והייתי סגור בארבעת צדדי" (עמוד 4 שורה 23 וכן סעיפים 17-18 לתצהיר). טענתו בכתב התביעה כי "השכן שגר בקומה התחתונה דירה 1 סגר לחלוטין את הגישה לביוב הראשי והמשותף של הבניין ואין לנו שום דרך אחרת כדי להגיע לביוב הראשי" הוכחה, בפשטות, כלא נכונה.

זאת ועוד. הוכח בפני כי לפתח הביוב ישנה גישה נוחה וקלה דרך הרחבת דירתו של השכן אפללו (תת חלקה 1) – "כיום אני מגיע למנול דרך המעבר בתוך הדירה של משפ' אפללו. הקומה התחתונה זה מתוך יחידה נוספת שהם בנו במרתף" (עמוד 5 שורות 28-27). בהקשר זה הוכח בפני כי ה"ה אפללו אף הותירו בדירתם דלת ייעודית לצורך מעבר לפתח הביוב (נספח ה' לתצהיר הנתבע). לא



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 147/11 + 132/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

עלה בידי התובע לשכנע אותי כי אין באפשרותו להגיע לפתח הבניין דרך הרחבת דירת אפללו כאמור.

בהקשר זה הובאה לעדות בפני גב' אפללו במסגרת דיון ההוכחות. אולם, לאור התנגדותו של התובע לעדותה, בהעדר תצהיר מטעמה, היא לא נשמעה (ר' החלטתי מיום 10.01.12). בנסיבות כפי שהוכחו בפני אי העדתה של הגב' אפללו עומדת לתובע לרועץ.

וידוגש, אומנם המדובר במעבר דרך דירה של אחר. אולם, גם מעבר דרך מחסן הנתבע הינו מעבר דרך "נכס של אחר" לאור ההסכם. המדובר בבית משותף אחד ולפיכך אין נפקות ממשית אם המעבר הינו דרך דירת אפללו או דרך מחסן הנתבע.

בהקשר זה אין זה גם סביר בעיני כי התובע בחר לנקוט בהליכים כנגד הנתבע בלבד, ולא גם כנגד ה"אפללו". בפרט כאשר הגישה למנהול דרך הרחבת דירת אפללו הינה נוחה יותר (מאשר דרך מחסן הנתבע שאין בו רצפה ו מעבר בטוח) ואשר ייעדו פתח ספציפי לטובת מעבר זה.

לאור כל האמור לעיל הרי שלא עלה בידי התובע לעמוד במאזן ההסתברויות הנדרש להוכחת תביעתו ולפיכך היא נדחת.

התביעה שכנגד

כשם שנדחתה התביעה העיקרית כאמור בהתבסס, בעיקר, על ההסכם, כך ראוי גם כי תידחה התביעה שכנגד בנוגע לדרישה להסרת קיר האבן מגג הבית.

ראשית, ההסכם קובע כי הגג המשותף יעבור לרשותו של הנתבע שכנגד. בהקשר זה גם קובע ההסכם כי הנתבע שכנגד רשאי לרצף את הגג וכן יכול "להקים מעקב מאבן או מבטון מסביב לגג". לא מקובלת עלי פרשנותו של התובע שכנגד לפיה ההסכם הקנה לנתבע שכנגד את הזכות להתקין מעקה מבטון רק "בהיקף לא באמצע. זה רק בשלוש צלעות" (עמוד 6 שורה 40). ההסכם אומנם קובע כי מותרת התקנת מעקה "מסביב לגג". אולם, אין בהסכם את ההרחבה אותה מפרש הנתבע כאילו ניתן להתקין את המעקה ב"שלוש צלעות" בלבד. ההסכם הוא כזה המקנה זכות שימוש לנתבע שכנגד ב"גג המשותף של צד א' וצד ב'", לרבות הזכות לגדרו. ברי כי זכות גידור זו מתייחסת לכל צדדיו של הגג שהוקנה לשימוש הנתבע שכנגד.

שנית, בהתאם להוראות ההסכם על הנתבע שכנגד היתה האחריות לטיפול "בבעיית הקיר המערבי". הנתבע שכנגד מעיד בהקשר זה – "הגענו להסכם לפתור את הבעיה בקיר המערבי שיש רטיבות גדולה, כדי לפתור את הבעיה הייתי חייב לבנות את הקיר על הגג, עם יריעה סביב כל הקיר, הוא ידע מזה" (עמוד 3 שורות 4-6) וגם בהמשך עדותו "עשיתי קיר כדי לפתור בעיה של רטיבות" (עמוד 4 שורה 16). טענה זו לא רק שלא נסתרה על ידי התובע שכנגד אלא שהוא אף אישר בעדותו כי עבודות הנתבע שכנגד בגג הסדירו את ליקויי הרטיבות – "נכון שהייתה רטיבות בקיר המערבי. ש.ת. נכון שלאחר שהוא טיפל בגג אין בעיה של רטיבות בקיר המערבי" (עמוד 6 שורות 36-37).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 132/11 + 147/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

משכך, ממילא, בהתאם להוראות ההסכם, רשאי היה הנתבע שכנגד להתקין את הקיר האמור ולמעשה אף היה חייב לעשות כן.

שלישית, ההסכם קובע כי "הדוד שמש של צד א' הרצל בנימין הנמצא על הגג המשותף הרצל ידאג להעביר אותו למקום אחר. מחוץ לגג המשותף" (סעיף ג' להסכם). כפי שניתן לראות בנספח ז' לתצהיר התובע שכנגד, דוד השמש עודנו מותקן על גג הבית. משכך, בהתאם ללשון ההסכם, על פי פרשנותו של התובע שכנגד לפיה המונח "גג" בסעיף ה' להסכם מתייחס לכל הגג ולא רק גג המשותף לצדדים (עמוד 6 שורה 39), הרי שהתובע שכנגד הוא זה המפר את הוראות ההסכם. על סמך הפרה זו מבקש הוא כי יינתן צו המורה על הריסה של קיר שנבנה כדין בהתאם לאותו הסכם.

רביעית, על פי עדותו של התובע שכנגד דוד השמש הותקן בשנת 2006 ועברו לפחות 4 שנים מאז הותקן הקיר ללא כל בעיה של מים חמים (עמוד 6 שורות 32-33). הסבריו של התובע שכנגד מדוע רק עתה הוגשה התובענה או כיצד זה שרק לאחר 4 שנים נתקל בבעיה בחימום המים בדוד (עמוד 6 שורות 27-28) אינם מקובלים עלי. מעדותו של התובע שכנגד עולה כי מדובר בתובענה קנטרנית שלא באה לעולם אלא כתגובה לתביעה העיקרית. ויוער, במסגרת התביעה שכנגד בחר התובע שכנגד להדגיש את התובענה הכספית שתידון להלן. התובענה לסילוק המעקה מהגג נטענה בפסקה אחת בלבד בשולי כתב התביעה.

חמישית, ממילא לא עלה בידי התובע שכנגד להוכיח כי הקיר גורם לקושי כלשהו בחימום המים (בפרט כאשר במשך שנים לא היתה כל בעיה כנ"ל כאמור לעיל). בהקשר זה הרי שהתובע שכנגד ויתר על עדות המומחה מטעמו.

למעלה מכך, אף אם ישנה הפרעה כלשהי לחימום המים, הרי שהפתרון הזול, היעיל והפשוט ביותר הינו הסטת הקולטים ולא הריסת הקיר.

בהקשר זה מקובלת עלי עדותו של הנתבע שכנגד – "בהסכם בינינו אני קיבלתי את כל הגג של הבית. עשיתי קיר כדי לפתור בעיה של רטיבות. אני בונה עוד קומה אז מה זה משנה לו הקיר הזה, יהיה לי היתר בנייה. את הקיר אני ממשיך לגובה בבנייה שלי. את הקיר עשיתי בהסכמה שלו, להוריד ולבנות זה עולה לי כסף. הבנייה של הקיר נעשתה ע"י מומחה. השמש כל היום על הדוד" (עמוד 4 שורות 16-19).

לאור האמור לעיל אין מקום לקבלת התביעה שכנגד להסרת הקיר מגג הבית.

בכל הקשור לתובענה לחיוב הנתבע שכנגד בהוצאות בסך של 15,000 ₪ בגין "עוגמת הנפש, הטרטור, והטרדה ואי הנעימות", הרי שהמדובר, למעשה, בבקשה לחיוב בהוצאות בגין ניהול ההליך העיקרי אשר לטענת התובע שכנגד הינו הליך שווא. אין מקום לפיכך להתייחס לעילת תביעה זו בנפרד מפסיקת ההוצאות בתיק העיקרי. ממילא גם אינני מוסמך לפסוק פיצוי בגין "עוגמת נפש" בהיותה, מעצם טיבה וטבעה, קשורה בעילה נזיקית שאיננה במסגרת סמכותי העניינית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 132/11 + 147/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

וידוגש, לו לא היה מגיש התובע שכנגד את ההליך מטעמו, הרי שהיה זוכה בפסיקת הוצאות לטובתו בגין ההליך העיקרי שנדחה. אולם, משבחר לנקוט בהליך שנדחה אף הוא, אין מקום לחיוב הדדי בהוצאות ההליכים.

סיכום

לאור כל האמור לעיל התביעה העיקרית נדחת.

לאור כל האמור לעיל התביעה שכנגד נדחת.

בנסיבות אלו בהן נדחו התביעות ההדדיות של הצדדים, נכון כי לא יינתן צו לתשלום הוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ל' ניסן תשע"ב, 22 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין